

1515732-44.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

DENIS MARQUES (RG 46709243-SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c.c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 25 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515732-44.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515732-44.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

DENIS MARQUES (RG 46709243-SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c.c o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque, no dia 25 de julho de 2020, por volta das 03h45min, na Rua Registro, 87, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios e propósitos com o adolescente Victor Hugo Batista Mariano, teria trazido consigo e tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega e

fornecimento a terceiros, 1553.4g (um quilograma, quinhentos e cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de maconha, 595ml (quinhentos e noventa e cinco mililitros) de Cloreto de Metileno/Diclorometano (lança-perfume), 17.4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de Anfetamina (ecstasy), 40.3g (quarenta gramas e três decigramas) de cocaína na forma de crack, bem como 145.2g (cento e quarenta e cinco gramas e dois decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 5/6) e sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 59/62).

A decisão a fls. 110/113 determinou a soltura do réu (fls. 206/209).

O acusado foi citado a fls. 216 e apresentou defesa preliminar (fls. 220/221). A denúncia foi recebida (fls. 222).

Durante a instrução foram ouvidos os policiais militares e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, com afastamento da aplicação da figura privilegiada e fixação do regime fechado.

A Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para a figura do art. 37, caput, da Lei 11.343/06 e a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado; e a fixação do regime aberto, bem como a substituição de privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada: boletins de ocorrência (fls. 14/16; 17/24); auto de exibição e apreensão (fls. 25/26); auto de constatação de substância (fls. 27/32); laudo definitivo toxicológico (fls. 121/124); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

O laudo definitivo comprova que as drogas apreendidas em posse do acusado eram: 1553.4g (um quilograma, quinhentos e cinquenta e três gramas e quatro decigramas) de maconha, 595ml (quinhentos e noventa e cinco mililitros) de Cloreto de Metileno-Diclorometano (lança-perfume), 17.4g (dezessete gramas e quatro decigramas) de Anfetamina (ecstasy), 40.3g (quarenta gramas e três decigramas) de cocaína na forma de crack, bem como 145.2g (cento e quarenta e cinco gramas e dois decigramas) de cocaína.

O policiais militares Ronaldo Jose da Silva e Rodolfo Stefano Marinelli de Oliveira afirmaram, em sede policial, que estavam em patrulhamento de rotina, por local que é conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram movimentação de um grupo de, aproximadamente, seis indivíduos em um beco (que termina em uma casa), aparentemente, para comprarem entorpecentes. Narram que acompanharam a movimentação destes indivíduos que dirigiam-se ao portão da referida casa, a qual encontrava-se aberto. Eles também visualizaram a movimentação que ocorria de dentro do portão, sendo que um indivíduo estava na função de "servir" os entorpecentes, por um acesso do portão, e estava com uma mochila. Quando se aproximaram, contam que o grupo dispersou, sendo que os policiais obtiveram êxito em abordar dois deles, aparentemente os compradores (antes de adquirirem os entorpecentes), e identificados como Moises Expedito de Araujo Souza e Victor Gomes da Silva. Aquele indivíduo que estava "servindo" os entorpecentes, ao perceber a aproximação dos policiais, ainda tentou fugir, mas foi abordado e identificado como Victor Hugo Batista Mariano, menor de idade. Com ele, havia um segundo rapaz, que tentou fugir por uma escada, mas foi detido no andar superior do imóvel, e identificado como Denis Marques. Verificou-se que parte das substâncias estavam sobre uma madeira, a fim de serem comercializadas, e outra parte, na mochila e numa bolsa, sendo encontradas as seguintes substâncias: 579 porções de substância aparentando ser maconha; 17 frascos contendo substância aparentando ser lança-perfume; 44 comprimidos aparentando ser ecstasy; 171 porções de substância aparentando ser crack, e 358 porções de substância aparentando ser cocaína. Também foram encontradas: uma mochila, uma bolsa, uma balança de precisão, 03 pedaços de papel, contendo anotações, aparentemente sobre a mercancia de entorpecentes, e 02 facas. Em poder do adolescente Victor Hugo, foi encontrada a quantia de R\$ 301,00, e em

poder de Denis, foi encontrada a quantia de R\$ 720,00. O adolescente, ao ser abordado, disse: "perdeu, senhor", enquanto Denis, num primeiro momento, alegou que era morador do local; entretanto, passou a conversar com adolescente, que disse: "já era"; após tais comentários, Denis solicitou aos policiais que avisassem seus familiares sobre a sua prisão. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Distrital, para as providências cabíveis.

Em juízo, o policial Ronaldo narrou que estava em patrulhamento e foram averiguar um ponto já conhecido por tráfico e viram vários usuários, como se fosse uma fila, até chegar uma residência, num beco, quando visualizaram dois indivíduos: um deles, adolescente, estava com a droga, e um outro, o réu, correu para dentro da residência. Falou que foram apreendidos os entorpecentes e uma certa quantia de dinheiro e que não se lembra se usuários foram abordados antes da compra, explicando que, se parassem antes, fardados, para conversar com usuários, os traficantes fugiriam. Relatou que havia um portão feito por eles, como uma barricada, para servir as drogas, e que deixaram o portão aberto. Disse que o réu estava junto, mas fugiu quando viu a viatura, pois tem uma escada para o andar de cima, mas como era fechado, sem saída, não teve como fugir. Esclareceu que a casa era abandonada, sem móveis, com restos de comidas por eles mesmos consumidas. Aduziu que a droga foi apreendida numa mochila de cor preta e que, na hora da prisão, não se lembra de os indivíduos se comunicarem entre si. Falou que, além da mochila, havia drogas em cima de uma tábua, separadas para entrega. Respondeu que não conhecia o réu antes da ocorrência e que havia duas viaturas da força tática, com mais dois policiais, totalizando quatro policiais. Aduziu que ninguém assumiu a propriedade da casa, e que o local é utilizado como ponto de tráfico. Falou que não havia mandado, e que viu o menor correndo, recolhendo as drogas, e já o abordou. Explicou que o andar de cima é uma laje, onde há tanto um cômodo quanto um espaço aberto, que dá acesso a outros telhados da comunidade.

Em juízo, o policial Rodolfo narrou que estava em patrulhamento e no local, perto de uma viela já conhecida pelo tráfico, viram pessoas saindo, provavelmente usuários, e visualizaram, num portão, ao final da viela, um indivíduo distribuindo drogas, um adolescente, e um segundo indivíduo, o corréu DENIS, tentando fugir pelo segundo andar, e ambos foram apreendidos. Falou que o menor (Victor Hugo) foi apreendido em posse de entorpecentes dentro de uma mochila, e aproximadamente R\$ 720,00, já o réu com apenas R\$ 301,00. Disse que pessoas se dirigiam até o portão e o menor, de dentro do portão, estava servindo os usuários, por um vão no portão. Aduziu que dois usuários foram abordados e levados, nesta condição, à delegacia. Falou que, quando visualizou o menor, o réu também estava no interior da residência, do lado de dentro do portão, que também correu por meio de uma escada para o andar de cima, onde foi apreendido. Relatou que ambos, inicialmente, falaram que eram olheiro, e só viu o menor servindo, não viu o réu servindo. Respondeu que não foi possível visualizar se mais pessoas estavam na casa e que as drogas estavam na mochila, mas algumas estavam espalhadas em cima de uma madeira. Explicou que o adolescente portava a mochila, e que os dois usuários confirmaram que estavam ali para comprar. Disse que não conhecia o réu antes. Falou que, quando o adolescente foi apreendido, este falou "perdeu, perdeu" para o réu, que respondeu "já era". Disse que o sargento Ronaldo e ele participaram, mas um ficou na viatura. Relatou que, antes da abordagem, umas seis pessoas foram avistadas, que estavam saindo da viela. Esclareceu que a casa estava abandonada, com lixo e fezes, e nenhum proprietário se identificou. Também disse que o portão era de ferro maciço, com buracos perto da fechadura. Relatou que não havia mandado judicial, mas entrou ao ver nitidamente o indivíduo servindo a droga, prendendo-o ao lado do portão, do lado de dentro, bem como o réu, na laje. Explicou que havia uma escada bem estreita, que não estavam usando câmera, que não havia outras pessoas, outros moradores, além dos usuários. Disse que o parceiro abordou o réu. Esclareceu que a madeira, em cima da qual foram encontradas drogas, era uma tábua, já que o chão, de cimento, era bem sujo.

O réu, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que trabalha no ponto de venda de drogas como "olheiro" há aproximadamente uma semana, pois encontra-se desempregado. Estava no movimento da venda de drogas quando policiais da Força

Tática chegaram. Disse ter corrido em direção a um telhado, mas acabou sendo abordado. Nega que tivesse com as drogas, facas e balanças, sendo que quem estava com elas conseguiu fugir. Também informou que não estava em posse da quantia de R\$ 301,00 (trezentos e um reais). Por fim, disse que os policiais militares lhe pediram um revólver calibre .38 para não ser preso.

Em juízo, o réu disse que na sua mão não tinha dinheiro algum e que estava no teto como olheiro, serviço pelo qual receberia 100 reais para trabalhar à noite. Aduziu que era o seu primeiro dia nesse trabalho, e que nunca teve problema com a justiça, nem quando era adolescente. Explicou que estava de campana, em seu primeiro dia, e que o menor já estava bem antes. Relatou que estava fazendo aquilo por necessidade. Confessou que atuava somente como olheiro, e que trabalharia das 9 da noite às 9 da manhã, para ganhar 100 reais. Respondeu que tem 8 filhos, dois quais 4 são de sangue e 4 são de criação, e estava desempregado.

A quantidade de drogas apreendida, com amplíssima variedade de entorpecentes e peso superior a um quilograma de drogas fornece indícios inequívocos da atividade de traficância. No mesmo sentido vai o encontro de anotações de tráfico, valores elevados em espécie (superando mil reais encontrados no poder do réu e adolescente) e outros instrumentos como balança.

Tendo em vista o depoimento policial, que acompanhara a atividade dos indivíduos, resta claro o envolvimento do réu com as atividades de traficância, o que até mesmo o próprio acusado confirma em seu depoimento, afirmando ser "olheiro".

Contudo, diferentemente do que alega o réu, de que estaria atuando somente como informante, o depoimento dos policiais não deixa dúvidas de que ele efetivamente atuava na traficância, já que fora avistado junto com o adolescente vendendo as drogas, e só correu para o interior da casa, subindo ao piso superior, após avistar as viaturas. Ele estava efetivamente participando da materialização do comércio das drogas, vinculando-se diretamente com os entorpecentes. Nada, portanto, indica que ele estaria atuando apenas como um "olheiro".

Além disso, o réu foi preso em flagrante delito, quando distribuía entorpecentes a vários usuários em uma casa abandonada, não havendo se falar, pois, em busca ilegal. A própria confissão do réu confirma que havia fundada suspeita para abordagem dos policiais, que avistaram o comércio ilícito de drogas, e procederam à apreensão dos entorpecentes, localizados ao lado do réu e do adolescente, que se encontravam junto ao portão do imóvel abandonado.

Por fim, ante a atividade coordenada do réu e do adolescente, resta comprovada a autoria relacionada ao inciso VI do artigo 40 da lei de Drogas.

Portanto, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de tráfico de entorpecentes acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, em razão da grande variedade e quantidade de drogas apreendidas.

Na segunda fase, a agravante constante do artigo 61, II, j, do Código Penal deve ser lida com cuidado, especialmente no que se refere à expressão "ou qualquer calamidade pública". A nítida impressão que se extrai do dispositivo é de que haveria a necessidade de o réu ter alguma facilidade para a prática delitiva em decorrência de certos acontecimentos ("incêndio", "naufrágio", "inundação"). Ou seja, alguém que se aproveitando de situações de debilidade que possivelmente está a vítima num momento de "incêndio", "naufrágio", "inundação", por exemplo, deve ter agravada a pena porque foram as situações indicadas que facilitaram a realização da conduta do agente ou tornaram a vítima vulnerável. Após os exemplos expressados pelo legislador ("incêndio", "naufrágio", "inundação"), vem uma cláusula: "ou qualquer calamidade pública". Ocorre que o raciocínio teleológico do dispositivo é "ou qualquer calamidade pública" que facilite a conduta do autor e/ou demonstre certa fragilidade da vítima quando da conduta, de modo que somente se ficar comprovado, no caso concreto, que a situação de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6 do Congresso Nacional e Decreto nº 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor em 20 de março de 2020) decorrente da pandemia (coronavírus disease 19 - COVID 19) facilitou ou demonstrou certa vulnerabilidade da vítima, é que se poderá agravar a pena. Ao revés, estaríamos diante de verdadeira responsabilidade

objetiva, o que não se admite quando se estuda a essência do Direito Penal. Então, verifica-se que no caso concreto a situação da pandemia em nada facilitou para a prática da conduta típica ou não ficou demonstrado que a vítima estava numa situação mais vulnerável em decorrência da pandemia. Em realidade, a depender das circunstâncias do caso concreto a situação da pandemia em questão poderia até mesmo configurar uma atenuante inominada (art. 66, CP), desde que também ficasse comprovada a circunstância relevante a justificar a minorante. Pelos motivos acima, afasto a agravante mencionada pelo Ministério Público na peça vestibular.

Ainda na segunda fase, reconheço a confissão do réu, ainda que parcial, retornando a pena para o seu patamar mínimo.

No que tange às causas de aumento e diminuição de pena, aplica-se o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343, dada a primariedade do réu, reduzindo-a na fração de 2/3. Deixo de considerar a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nesta fase, uma vez que já consideradas para a fixação da pena-base, evitando-se, assim a ocorrência do bis in idem.

Considerando que o crime envolveu a participação de adolescente, incide o aumento de pena na fração de 1/6, nos termos do artigo 40, inciso VI, da lei 11.343/2006. Então, a pena definitiva será de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 193 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena do réu, ante a quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, Código Penal.

Viável a substituição da pena por restritivas de direitos à acusada, tendo em vista a primariedade do réu e o crime ter sido cometido sem violência ou grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DENIS MARQUES (RG 46709243-SP) como incurso no artigo 33, caput, e § 4º, e artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. A pena privativa de liberdade deverá ser substituída por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da reclusão, e pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.

O réu deverá responder ao processo em liberdade, ante a quantidade de pena aplicada, a fixação do regime inicial diverso do fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o crime ter sido praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, de modo que estão ausentes justificativas quaisquer para a manutenção da prisão preventiva, consoantes os argumentos a fls. 110/113. Além disso, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo em liberdade e assim deve permanecer caso deseje apelar.

Oficie-se para destruição das drogas e objetos apreendidos.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União, por se tratar de bem proveniente da prática de tráfico, de acordo com o art. 63 da Lei 11.343/06.

P.I.C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA